

第61問

甲は、公園付近を歩いていたところ、偶然、見知らぬ女性（A）がベンチに鞆を置いたまま、その場から徒歩で立ち去るのを目撃した。甲は、1分ほどAの様子をうかがっていたが、鞆に気付いて戻る気配がなかったため、鞆に近付き、中をのぞいたところ、有名ブランド製の財布とコインケースを見つけた。そこで、甲は、財布とコインケースを自宅まで持ち去った。そのため、ベンチを離れてから約5分後に、鞆を置き忘れたことに気が付いたAが慌てて戻ったときには、既に鞆から財布とコインケースが抜き取られている状態であった。

翌日、甲は、妻である乙に対して事情を伝えた上で、財布の保管を依頼した。乙は、Aという見知らぬ女性にとっては気の毒な話だと思いながらも、警察に届けるわけにもいかないと思い、甲の依頼を承諾することにして、財布を受け取り、自己のタンスにしまった。

一方、甲は、友人の丙と会い、昨日の出来事について話をした上で、Aのコインケースを示した。すると、丙は、「Aとは面識がある。このコインケースはAが大事にしていた物だから、うまく言えば、高値で買い取ってくれると思う。」などと述べたため、甲は、丙に対して、コインケースの売却を依頼した。丙は、これに応じて、Aに対して、「今、買い取らないと、二度と手に入らなくなる。」などとほのめかし、コインケースを時価相当額である2万円で売却し、後日、これを甲と折半した。

甲、乙及び丙の罪責について、論じなさい。

第1 甲の罪責

1 Aの財布とコインケースを持ち去った行為について

窃盗罪（235）の成否を検討することになる（**論点** 占有の有無の判断方法 **論** 司H27）。

占有とは、「人が物を実力的に支配する関係」（最判昭32.11.8。なお、「必ずしも物の現実の所持又は監視を必要とするものではなく、物が占有者の支配力の及ぶ場所に存在するを以て足りる」とされていることには注意）であって、占有の事実と占有の意思の両面からなる。

本問のように、公衆が自由に出入りできる場所に財物を置き忘れた場合には、行為の時点における被害者の財物との場所的・時間的離隔が第一次的に重要視されるべきである（最決平16.8.25【百選Ⅱ28】）。

本問では、甲は、Aが立ち去ってから1分後に、Aの財布とコインケースを領得しているから、場所的・時間的離隔が小さい。したがって、占有を肯定することができる。

なお、Aは、ベンチを離れてから約5分後に鞆を置き忘れたことに気が付いた事情も占有を肯定する一事情ではあるが、これはあくまでも補充的に考慮し得るにすぎない。また、甲は、Aが鞆を置き忘れたところを目撃しているが、占有の有無の判断に当たってこれを考慮に入れることができるかという点に争いがある。

2 その後、コインケースを売却した行為は、不可罰的事後行為となる。

総合 195 頁 **論証** 82 頁

第2 乙の罪責

1 甲から財布を預かった行為について、盗品等保管罪（256Ⅱ）が成立する。

2 もっとも、甲と乙は夫婦であるから、257条1項の適用があるかが問題となる（**論点** 257条1項における親族関係は犯人と誰との間に必要か **論** 旧H10-2）。判例（最決昭38.11.8）は、「本犯と贓物に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、贓物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものである」とするため、本問でも同項の適用がある。

総合 261 頁 **論証** 132 頁

第3 丙の罪責

甲の依頼を受けて、Aにコインケースを売却した行為について、盗品等有償処分あっせん罪（256Ⅱ後段）を検討することになる。

問題は、被害者であるAに売却しているため、追求権侵害とならないのではないかという点である（**論点** 盗品等関与罪の保護法益と罪質 **論** 旧H19-2、**論点** 被害者への返還と有償処分あっせん罪）。

この点について、本罪の処罰根拠を、追求権侵害を中心に考える立場からしても、対価を要求することは、被害者による盗品の正常な回復を困難にするという意味で追求権侵害があると解し、同罪の成立を認めることができる。判例（最決平14.7.1【百選Ⅱ75】）も、「盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は、窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても、被害者による盗品等の正常な回復を困難にするばかりでなく、窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれのある行為であるから、刑法256条2項にいう盗品等の『有償の処分のあっせん』に当たると解するのが相当である」としている。

総合 260 頁 **論証** 130 頁
論証 130 頁

答案構成

第1 甲の罪責

1 窃盗罪の成否(235)

↓

2 「窃取」とは、意思に反した占有侵奪をいう

↓

占有の有無をいかに判断すべきか

↓

刑法上の占有は人が物を実力的に支配する関係であって、占有の事実と占有の意思から構成されるが、その有無は、社会通念によって決するほかはない

↓

公衆が自由に入出入りする場所に財物を置き忘れた事案の場合には行為の時点における被害者と財物との場所的・時間的離隔が第一次的に重要視されるべき

↓

3 あてはめ

↓

「窃取」に当たる

↓

4 窃盗罪成立

第2 乙の罪責

1 盗品等保管罪(256Ⅱ)成立

↓

257条1項の適否

↓

2 誰と誰との間に親族関係が必要か

↓

本犯と盗品等に関する罪の犯人との間に必要である

↓

あてはめ

↓

257条1項で刑が必要的に免除される

第3 丙の罪責

1 盗品等有償処分あっせん罪(256Ⅱ)の成否

↓

窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合であっても成立するか

↓

肯定説

↓

2 丙には盗品等有償処分あっせん罪が成立する

第1 甲の罪責

1 甲がAの財布及びコインケース（以下、それぞれ「本件財布」、「本件コインケース」という。）を持ち去った行為について、「他人の財物を窃取した」ものとして、窃盗罪（235条）の成立可能性がある。

2 窃盗罪の実行行為は「窃取」、すなわち意思に反した占有侵奪であり、被害者に占有が認められない場合には同罪は成立せず、占有離脱物横領罪（254条）が成立するにとどまる。そこで、占有の有無をいかに判断すべきか。

刑法上の占有は人が物を実力的に支配する関係であって、占有の事実と占有の意思から構成される。そして、その支配の態様は物の形状その他の具体的事情によって一様ではないため、社会通念によって決するほかはない。

具体的には、財物の置き忘れのような事案では、領得行為時における被害者と財物との時間的場所的近接性、忘れた場所の開放性、被害者が忘れた場所を明確に記憶していたかどうかなどの諸要素を総合的に考慮すべきである。そして、公衆が自由に出入りする場所に財物を置き忘れたような事案の場合には、行為の時点における被害者と財物との場所的・時間的離隔が第一次的に重要視されるべきである。

なお、占有の有無の判断は客観的になされるものであるところ、行為者の主観は故意の成否に当たって問題とすべき事情であり、占有の有無の判断に取り込むべきではない。

3 本問では、誰もが自由に出入りすることができる公園であって、場所

1

の開放性は強い。

そして、甲は、Aが立ち去ってから、わずか1分後に本件財布及び本件コインケースを領得している。また、Aは歩いて立ち去ったため、未だ近接した場所にいると思われる。

したがって、甲の上記行為の時点における被害者Aと本件財布及び本件コインケースとの場所的・時間的離隔は非常に小さい。

この事実から、Aに本件財布及び本件コインケースの占有を認めることができる。

さらに、Aは席を立てから5分後に鞆を置き忘れたことに気付いて慌てて戻っている。このことから、Aは本件財布及び本件コインケースを置き忘れた場所を明確に記憶していたと考えられ、Aの占有の意思も比較的強く認められる。この事実からも、Aの占有を基礎付けることができる。

したがって、甲の上記行為は、Aの意思に反した占有侵奪であり、「窃取」に当たる。

4 甲には、故意（38条1項）及び不法領得の意思に欠けるところもないから、窃盗罪が成立する。

第2 乙の罪責

1 乙が、甲から、本件財布を盗品であることを知りながら受け取り、自己のタンスにしまった行為について、「盗品」（256条1項）を「保管」したものとして、盗品等保管罪（同条2項）が成立する。もっとも、甲と乙は夫婦であり、「配偶者」に当たるから、257条1

2

1 項の適用があり、刑が免除される可能性がある。一方で、被害者たるA
2 との間には、親族関係がない。

3 そこで、同項が適用されるためには、誰と誰との間に親族関係が必要
4 なのか、問題となる。

- 5 2 盗品等関与罪の犯人が親族たる本犯者を保護したり、本犯者の利益に
6 預かったりするために本犯の犯罪に関与することは社会類型的によくみ
7 られるところであり、また、そのような関与は期待可能性が乏しいとい
8 える。

9 それゆえ、257条1項は、盗品等関与罪が、被害者の追求権を侵害
10 するのみならず、本犯者庇護という事後従犯的側面を有することを併せ
11 て考慮し、親族が本犯の場合には、適法行為の期待可能性が減少するこ
12 とを理由に、一身的に処罰を阻却し、刑の免除を認めたものであると考
13 えられる。

14 そうだとすれば、同項所定の親族関係は、本犯者と盗品等関与罪の犯
15 人との間に必要であると解すべきである。

- 16 3 本問では、盗品等に関する罪の犯人乙からみて本犯者甲は夫であり、
17 「配偶者」に当たるため、257条1項の適用があり、刑が必要的に免
18 除される。

19 第3 丙の罪責

- 20 1 Aに対して本件コインケースを2万円で買い取らせた行為について、
21 「盗品」の「有償の処分あっせんをした」ものとして、盗品等有償処
22 分あっせん罪（256条2項後段）が成立する可能性がある。

3

1 もっとも、Aは本件コインケースの所有者であり、かつ甲による窃盗
2 の被害者である。このような場合であっても、同罪は成立するか。

3 上記のように、本罪の処罰根拠は、被害者の追求権侵害及び事後従犯
4 的性格に求められる。

5 この点について、窃盗等の被害者を処分の相手方とする場合には、被
6 害者による盗品の回復を困難にしておらず、追求権侵害は認められない
7 かに思える。

8 しかし、被害者による盗品の正常な回復を困難にするという意味で追
9 求権侵害があるというべきである。

10 また、窃盗等の犯罪を助長し誘発するおそれがあるのだから、上記の
11 ような場合であっても、事後従犯的な性格は失われない。そのため、そ
12 のような観点からも可罰性を基礎付けることができる。

13 したがって、上記のような場合でも盗品等有償処分あっせん罪が成立
14 すると解すべきである。

- 15 2 以上から、丙には盗品等有償処分あっせん罪が成立する。

16 以 上

4